

1501044-60.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... fls. 78/80. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O policial civil Márcio Luiz Teixeira De Camargo Barhun, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que, na data dos fatos, realizando investigação de tráfico de drogas no local dos fatos, e o depoente permaneceu sozinho, em viatura ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501044-60.2022.8.26.0599 - Controle nº 2022/000896

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2189077/2022 - GOE-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHA FELIPE ALMENARA

Réu Preso

Aos 13 de dezembro de 2022, às 14:15h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao disposto no Provimento CSM 2651/2022, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: JONATHA FELIPE ALMENARA - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC MARCIO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO BARHUN - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC ANDRE AUGUSTO PIRES - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos das testemunhas PC MARCIO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO BARHUN e PC ANDRE AUGUSTO PIRES.

Após, o réu JONATHA FELIPE ALMENARA foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ. A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "JONATHA FELIPE ALMENARA, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 90/92. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 121), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 125/126), sendo a denúncia recebida (fls. 127/129). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu, por fim, interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08, fotografia de fls. 09 e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 78/80. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O policial civil Márcio Luiz Teixeira De Camargo Barhun, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que, na data dos fatos, realizando investigação de tráfico de drogas no local dos fatos, e o depoente permaneceu sozinho, em viatura descaracterizada, quando visualizou o réu, que pegava algo homiziado em um cano de água na calçada da via e entregava a outra pessoa, recebendo algo em contrapartida. Viu que o réu praticou essa conduta realizada por diversas vezes e diante disto, entrou em contato com o policial André e transmitiu as características físicas, de vestimenta e o local onde o réu se encontrava. André localizou o indivíduo no local dos fatos, quando o investigado avistou a chegada do policial dispensou algo embaixo de um veículo estacionado, realizada abordagem em revista pessoal com ele nada de ilícito fora encontrado, realizando busca embaixo do veículo localizou um saquinho contendo vinte e sete pedras de substância aparentando ser crack. No mesmo sentido foram as palavras do policial civil André Augusto Pires, o qual acrescentou que os policiais do GOE se dividiram de modo que o policial Barhun permaneceu sozinho, em viatura descaracterizada, enquanto o depoente permaneceu com o restante da equipe, em viatura caracterizada, nas imediações do referido bairro. Em dado momento o policial Barhun lhe telefonou e narrou que havia observado um indivíduo que atendeu algumas pessoas, entregando-lhe algo e delas recebendo algo em troca, passando-lhes suas características físicas e de vestimentas. Disse ainda que tal indivíduo pegava algo escondido em um cano de água na calçada da via e entregava ao interlocutor, recebendo algo em contrapartida.. O depoente localizou o acusado e viu o momento em que ele, ao ver a viatura, dispensou algo embaixo de um veículo que estava estacionado na via pública. Em revista pessoal nada de ilícito foi localizado, embaixo do veículo foi localizado um saquinho plástico contendo 27 pedras de crack. Questionado, o acusado confessou que estava realizando a venda de drogas, que havia pegado um kit com 27 pedras de crack para comercializar e que venderia pelo valor de 5 reais cada. Por fim, interrogado, o réu negou os fatos a si atribuídos, alegando que havia vendido sua reciclagem e comprou drogas para ir usar, tendo de fato dispensado a droga ao ver a viatura. Negou que os entorpecentes fossem para venda, e sim para seu próprio uso. Disse que havia comprado por cento e trinta reais e vinte e sete pedras. Assim, em que pese a negativa do réu quanto aos fatos, sua versão não deve prevalecer, vez que dissonantes e isoladas das demais provas coligidas nos autos, não encontrando nelas qualquer respaldo. De fato, insta ressaltar que, em que pese a alegação do acusado, os policiais foram uníssomos ao afirmar que o acusado foi flagrado por mais de uma vez atendendo as pessoas que o procuraram, entregando-lhes algo e delas recebendo algo em troca, bem como que indagado, o acusado confirmou informalmente que estava no local traficando para sustentar seu vício. Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos policiais são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho: O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente

quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. Ainda nesse sentido: PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei). Destarte, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Quanto à aplicação da reprimenda, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, haja vista que o acusado ostenta maus antecedentes (autos nº 0014846-81.2010 - fls. 94). Na segunda fase, verifica-se que o réu é duplamente reincidente, inclusive específico (autos nº 0013063-83.2012 - fls. 93/94; e 0025466-55.2010 - fls. 94/95). Na terceira fase, ante a reincidência, inaplicável o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da exordial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao denunciado, razão pela qual deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Marcio, Policial Civil, declarou que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico. O réu realizava a venda das drogas e colocava os entorpecentes em um cano de água. Ele atendeu algumas pessoas e mudou do local onde estava. Por conta disso, avisou sua equipe. O réu, então, jogou um saco embaixo de um carro. Os seus colegas abordaram o réu e, com ele, nada foi localizado. Porém, acharam o saco com as drogas embaixo do carro. A testemunha Andre, Policial Civil, declarou que foi acionado pelo Policial Marcio, o qual informou que, no Jardim Esplanada, existia uma pessoa vendendo drogas. Instantes antes da abordagem, viu que o réu jogou um objeto embaixo de um carro. Abordaram o réu e recuperaram o objeto dispensado. Tratava-se de um saco plástico contendo 27 porções de crack. O acusado confessou informalmente que estava vendendo drogas. Não conhecia o acusado antes dos fatos. O réu, em interrogatório, declarou que vendeu alguns objetos para reciclagem e comprou as drogas para seu consumo pessoal. Estava indo consumir os entorpecentes quando foi abordado pelos Policiais. Comprou R\$ 130,00 de drogas, foi o que tinha ganhado com a reciclagem. Recebeu um kit de drogas, continha 27 pedras e ganhou uma (o valor seria R\$ 135,00). Não falou para os Policiais que estava vendendo drogas. Costuma usar por dia o que consegue de dinheiro pedindo no sinal, olhando carros, etc. Não portava dinheiro quando foi preso, é usuário. Não conhece os Policiais que fizeram a sua prisão. É usuário de drogas desde os 12 anos. Não tem nenhum envolvimento com facção criminosa. Antes de ser preso, vivia em situação de rua. Portanto, Excelência, o acusado nega a prática dos fatos. Sua negativa deve ser considerada um elemento probatório, afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais provas dos autos. Isso porque, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Policiais responsáveis pela prisão do acusado, as quais, todavia, devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança pública do Estado ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem em Juízo a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos.

Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras de Policiais ou outros agentes de segurança como fundamento para uma condenação: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger." (TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito das declarações dos Policiais e da "movimentação suspeita" supostamente visualizada, não é possível afirmar, com certeza, que as condutas se tratavam efetivamente de um ato de venda de drogas, eis que os supostos compradores não foram apresentados na Delegacia de Polícia e não existem outras testemunhas presenciais dos fatos. Além disso, as substâncias não estavam sob a posse direta do acusado, eis que seu encontro ocorreu em um local aberto, de livre acesso a qualquer indivíduo. Ressalta-se, ainda, que a mera afirmação de que o endereço da abordagem seria conhecido como um "ponto de tráfico" não é presunção absoluta do envolvimento do réu na prática do crime, eis que, nesses lugares, circulam tanto indivíduos que se dedicam ao comércio de drogas quanto usuários das substâncias. E, diante das declarações do réu em seu interrogatório, é perfeitamente plausível que as condutas visualizadas pelos Policiais, na realidade, se tratavam de um ato de compra de drogas por parte do réu, sendo que o verdadeiro responsável pela venda seriam os indivíduos que não foram abordados. Por fim, cumpre observar que a suposta confissão informal do réu, além de constituir uma circunstância aberrante, que destoa do ordenamento jurídico, não foi confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Portanto, diante das provas produzidas, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Entretanto, na hipótese deste E. Juízo afastar o pleito absolutório, requer-se, ao menos, diante das declarações do acusado em seu interrogatório, a DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. Isso porque, com a devida vênia, há de se reconhecer que não há nos autos indícios de que o acusado fosse comercializar as drogas apreendidas, sendo que, reitera-se, não foi verificado qualquer ato efetivo de mercancia dos entorpecentes. Assim, no máximo, o réu poderia ser responsabilizado por portar drogas para fins de consumo pessoal, pois não foi demonstrado cabalmente o intuito lucrativo, não bastando a simples apreensão do entorpecente em poder do acusado para se justificar uma condenação por tráfico. Vale observar, ainda, que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder do réu nada diz quanto à sua destinação, eis que a quantidade necessária para a satisfação de um usuário é completamente variável. Para a configuração do crime de tráfico, não basta a simples apreensão da droga, sendo imprescindível a aferição de prova cabal da finalidade de mercancia dos entorpecentes por parte do réu, o que não foi o caso. Todavia, caso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, MESMO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. Isso porque, ainda que considerado reincidente, vale lembrar que a Lei de Drogas, ao fixar como pena mínima, para o delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, a causa de diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para primários, acaba por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que

presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que ele integre organização criminosa), é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no patamar de 2/3, implicando a sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela ausência de aplicação da causa de diminuição, uma pena de 5 (cinco) anos. O peso da reincidência, portanto, é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 (um terço) da pena, sendo 2/3 (dois terços) aplicados em função da reincidência. Essa desproporção também é inconstitucional porque atribui, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência implica a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (ou seja, em face de seus antecedentes) e não em função do ato por ele praticado. Como afirma Muñoz Conde: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFE, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso

suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo Juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência.” (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Por fim, nem se diga da impropriedade de se afastar uma regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas ou exortações políticas. Mais ainda: trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao eu julgamento, por força do disposto no §1º do art. 5º, da Constituição (“O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos”, in Direitos Humanos – Visões Contemporâneas, edição de Associação Juizes para a Democracia, 2001). Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, sendo que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao acusado, ressaltando-se que a sua vida pregressa deve ser valorada somente na segunda fase, a fim de se evitar eventual bis in idem com eventual agravante da reincidência; (ii) a incidência, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea (ainda que informal), compensando-a com a agravante da reincidência; (iii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iv) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ e, ainda, em razão do disposto no art. 387, § 2º, do CPP; (iv) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize,

neste momento processual, a manutenção de sua prisão preventiva".

Então, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

JONATHA FELIPE ALMENARA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 13 de julho de 2022, por volta das 10h, na Rua Vasco da Gama, nº 313, Bairro Esplanada, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 27 (vinte e sete) porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 3,2g (três gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais civis realizavam campanha pelo local dos fatos, já conhecido ponto de venda de drogas, quando visualizaram o acusado em atividade típica de tráfico, eis que manteve contato com duas pessoas, pegando algo homiziado em um cano de água, entregando aos interlocutores e recebendo algo deles em contrapartida. Em razão disso, os investigadores se deslocaram até o local onde JONATHA estava, tendo o acusado, ao avistar a equipe policial, dispensando algo sob veículo estacionado na via pública. Ato contínuo, os policiais diligenciaram embaixo do automóvel onde JONATHA dispensou algo antes da abordagem e apreenderam os entorpecentes retro descritos. Indagado, o réu confessou informalmente aos policiais a prática delitiva.

O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 121) e apresentou defesa preliminar (fls. 125/126), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia (fls. 127/129).

Designada audiência, foram ouvidas duas testemunhas. Após, o réu foi interrogado. As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do acusado.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08, pelas fotografias de fls. 09, 18 e 19, e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 78/80, que trouxe resultado positivo para cocaína.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu fez uso do direito de permanecer em silêncio (fls. 04)

Em juízo, afirmou que era morador de rua, usuário de drogas e pegava reciclagem.

Alegou que, no dia dos fatos, conseguiu alguns objetos, vendeu e, com R\$ 130,00, conseguiu comprar uma quantia maior de drogas. Declarou que cada porção custava R\$ 5,00 e ainda recebeu uma a mais. Porém, segundos após, foi abordado pelos policiais, que o acusaram de estar vendendo entorpecentes. Sustentou que é apenas usuário de drogas.

A prova produzida, porém, é maciça e incriminadora.

Com efeito, o policial civil Márcio narrou que estava em local já conhecido como ponto de tráfico e observou que um indivíduo fazia a venda e deixava a droga num cano de água. Disse que, em determinado momento, ele se aproximou da Rua Benjamim Constant, com saquinho de salgado na mão, momento em que acionou a viatura. Atestou que ele dispensou esse saco embaixo de um veículo. Aduziu que a equipe chegou e abordou o indivíduo, vindo a localizar, embaixo do carro, vinte e sete porções de crack.

O policial André Augusto relatou que foi acionado pelo policial Marcio com informação de que havia uma pessoa comercializando entorpecentes, tendo passado suas características. Disse que, no local da abordagem, observou que a pessoa jogou um objeto embaixo de um carro. Atestou que, feita a abordagem, vistoriaram o local onde ele dispensou o objeto e encontraram um saquinho com porções de crack. Aduziu que o réu confessou que estava comercializando.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais

civis não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais é tão válida quanta outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes. Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Enfim, o fato de os policiais civis, durante campanha no local, terem flagrado o acusado praticando atos típicos da traficância, vindo a localizar 27 (vinte e sete) porções de "crack" que ele havia dispensando debaixo de um automóvel, o que não foi infirmado por nenhum elemento de prova, conduz à certeza quanto a autoria e a traficância.

Anoto que a quantidade de entorpecentes apreendida e a forma como estavam acondicionados, aliados ao local dos fatos, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, e à flagrância de atos típicos de traficância, deixam mesmo evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 00038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Consigno, outrossim, que o fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498).

Na mesma esteira o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: "(...) muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente" (STJ - REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06.03.2018).

Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, observo que o réu é reincidente (fls. 93/96). Entretanto, essa circunstância só pode ser considerada na segunda fase de fixação da pena, evitando-se "bis in idem". Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no seu valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, está presente a agravante da reincidência, inclusive específica (autos nº 0013063-83.2012 da 3ª Vara Criminal local, nº 0014846-81.2010 da 1ª Vara Criminal local e nº 0025466-55.2010 da 2ª Vara Criminal local - fls. 93/96), razão pela qual aumento a pena em um quinto, resultando seis anos de reclusão e 600 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Inexistem causas de aumento e, por ser reincidente, não faz "jus" o réu à redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, em decorrência da reincidência específica e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a qual não pode ser tornada insubsistente, sobretudo em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça: "Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.). Comprovada a origem ilícita do dinheiro apreendido, declaro seu perdimento.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, CONDENANDO o réu JONATHA FELIPE ALMENARA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, no valor unitário mínimo, fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena e vedado o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra preso e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Declaro perdido o dinheiro apreendido.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

A seguir, pela MMª. Juíza foi deliberado o seguinte:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por

TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

2) Recebo o recurso interposto.

3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.

4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.

6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 12/12/2034.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MM^a. Juíza de Direito da 4^a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo

JUÍZA DE DIREITO

[Assinado eletronicamente]